

1500173-09.2022.8.26.0024

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... como reincidência, além de uma condenação por tráfico passível de ser considerada como antecedente criminal.

Assim, duas das condenações serão valoradas na primeira fase e duas na segunda.

Portanto, na primeira fase, deve a pena ser exasperada em 1/8, 9 meses de reclusão e 43 dias-multa, conforme critério de cálculo acima explicitado (encontro da fração a partir do intervalo entre ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500173-09.2022.8.26.0024 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500173-09.2022.8.26.0024

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2030490/2022 - 01º D.P. ANDRADINA, 22784338 - 01º D.P.

ANDRADINA, 2030490 - 01º D.P. ANDRADINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON DE OLIVEIRA PAES e outro

Réu Preso

O Ministério Público ofereceu denúncia contra JEFFERSON DE OLIVEIRA PAES e WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA PAES imputando-lhe a prática do crime de furto qualificado (Art. 155 § 4º, I, II, IV do CP).

Narra a denúncia que no dia 02 de fevereiro de 2022, por volta das 12h15min, na construção havida na Rua Espírito Santo, nº 287, Benfica, nesta cidade e comarca de Andradina: os réus qualificado a fls.05 e 07/09 e às fls.108/109 e 115, dos presentes autos, atuando em concurso e com unidade de desígnios, tentaram subtrair para si, mediante escalada e rompimento de obstáculos, um tambor de ferro, de 200 litros, cor amarela, avaliado em R\$ 200,00 (cf. auto de avaliação de fls.22), pertencente à sociedade empresarial "Concresp Empreendimentos", somente não consumando seu intento em virtude de circunstâncias alheias a sua vontade.

A denúncia foi recebida em 22 de fevereiro de 2022 em decisão de fl.143. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação de fls.158/160 e 164/166.

Após regular instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado, mas com afastamento das qualificadoras; a d. Defesa de Jefferson, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória ou por conta da atipicidade do fato, com

pedidos subsidiários (afastamento das qualificadoras, reconhecimento da confissão espontânea, das causas de diminuição de pena, descrita nos artigos 14, inciso II e 28, I, §2º, do CP, com regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade); a d. Defesa de Wesley, a seu turno, requereu o reconhecimento da atipicidade do fato, afastamento das qualificadoras, além de pedidos subsidiários como pena no mínimo, diminuição pela tentativa e confissão, regime aberto e conversão da pena.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do mérito da lide.

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela parcial procedência da acusação, afastando-se as qualificadoras relativas ao rompimento de obstáculo e à escalada (mantida apenas a de concurso de agentes).

Com efeito, a ocorrência do delito foi demonstrada pelos elementos da investigação (APF de fl.01, termo de depoimento de fls.02/03, termo de declarações de fl.04, termo de interrogatório de fl.05, boletim de ocorrência de fls.16/18 e 97, autos de exibição e apreensão de fl.21, fotografia de fl.23, laudos periciais de fls.131/142), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A autoria também foi comprovada pelos elementos indicados, assim como pela prisão em flagrante e consistentes relatos das testemunhas.

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, foi no seguinte sentido:

A vítima Juliana Rodrigues Gonçalves de Almeida narrou que quando chegou ao local, os acusados já estavam presos. Não houve prejuízos porque tudo foi devolvido. Já ocorreram outros fatos, inclusive com arrombamento, mas não sabe dizer se o fato específico dos autos envolveu arrombamento. A obra está toda cerca com alambrado. Confirmou que anteriormente já havia ocorrido outro fato com arrombamento.

O policial militar e testemunha Maurício dos Santos de Araújo disse que faziam patrulhamento e avistaram os réus no local, sendo que um deles pulava de dentro para fora da construção e o outro estava com um tambor. Relatou que Jefferson estava com o tambor e o outro era o Wesley, conhecido como "Xuxo". Detiveram o Jefferson. Ele falou que o rapaz que tinha fugido era irmão dele e que eles pegaram o tambor para vender. O local é alto, é necessário escalada para ingressar.

Constatarem que havia um contêiner com cadeado rompido. No dia o tempo estava chuvoso, então não foi possível atestar se era recente ou não o arrombamento.

Questionaram a representante da empresa sobre o valor do objeto e ela disse que aproximadamente R\$ 200,00.

Rogério Fernando da Silva, também policial militar e testemunha confirmou a versão de seu colega, sem divergências relevantes ou acréscimos dignos de nota.

Interrogado, o réu Wesley confirmou a subtração, negando apenas a escalada e arrombamento. Disse que seu irmão estava bêbado, mas por derradeiro acabou por confirmar sua participação.

Por sua vez, Jefferson confessou os fatos, dizendo que estava embriagado mas ainda com "um pouco de noção" e consciente de que praticariam um furto.

Diante desse contexto probatório, não há dúvidas de que a imputação do delito de furto qualificado é parcialmente procedente.

De início, certo que ambos os réus confessaram os fatos, o que converge com os depoimentos dos policiais, que narraram de forma consistente terem flagrado o momento em que os acusados tentavam praticar a subtração.

Nesse passo, restou devidamente demonstrado que Wesley ingressou no local e jogou o tambor, com valor de cerca de R\$ 200,00, para seu irmão Jefferson, que estava do lado de fora. Justamente neste momento, no limiar de consumação, é que foram flagrados pela polícia.

E o testemunho dos policiais não deve ser desacreditado apenas pela sua condição funcional. Não demonstraram ser tendenciosos ou qualquer especial disposição para prejudicar o réu, devendo o seu testemunho ser valorado como qualquer outro. Esta é a jurisprudência já pacífica sobre a condição de testemunha dos policiais militares

e outros agentes de segurança.

Com relação às qualificadoras de escalada e arrombamento, entretanto, deve ser adotada solução diversa, já que a representante da vítima disse que outros fatos com arrombamento já teriam ocorrido no local, os réus negam terem praticado tal conduta, e os policiais e laudos não conseguiram apontar se os rompimentos eram recentes ou não. Assim, a prova mostra-se duvidosa. Diga-se o mesmo sobre a escalada, vez que pelas características do local é possível que o acesso tenha se dado por via normal.

Inviável também o acolhimento de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto.

Nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, o reconhecimento da incidência do princípio depende de uma minuciosa análise de requisitos objetivos, relacionados ao fato, e requisitos subjetivos, vinculados ao agente e a vítima.

Por tais motivos, seu cabimento deve ser avaliado com base nas peculiaridades de cada caso concreto, e não no plano meramente abstrato (Nesse sentido: STF: HC/123.108/MG, rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.08.2015, noticiado no Informativo 793 e STJ: AgRg no RHC 44.461/RS, rel. Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, j. 27.05.2014, noticiado no Informativo 542).

O Supremo Tribunal Federal (HC 84.412-0/SP) idealizou quatro requisitos objetivos para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em apreço, o valor do objeto que se visava subtrair supera os parâmetros normalmente estabelecidos (10% do salário mínimo) pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para a insignificância (STJ - AgRg no REsp 1744802 MS 2018/0131490-7 e STJ - AgRg no AREsp 946939 MS 2016/0176618-5).

Some-se a isso o fato de os réus serem reincidentes, apresentando conduta voltada para a criminalidade.

Não obstante, o fato também não pode ser tido como insignificante em razão da presença de qualificadora, denotando-se a gravidade concreta da ação.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que o rompimento de obstáculo para a prática do crime de furto denota a maior reprovabilidade da conduta dos agentes e afasta, por conseguinte, a incidência do princípio da insignificância. 2. O Tribunal regional, ao apreciar o recurso defensivo, decidiu em consonância com o entendimento desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 746.011/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 23/11/2015)

Por tais motivos, deixo de aplicar tal princípio e reconheço o fato como típico. Ademais, quanto ao alegado entorpecimento no momento do fato, anoto que a embriaguez não exclui a imputabilidade, na forma do CP 28, II. Trata-se, ademais, de embriaguez voluntária, cabendo assim responsabilidade do corréu Jefferson, já que a causa de diminuição exige embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior.

Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

Critérios para fixação da pena:

Antes de iniciar a fixação da pena propriamente dita, cabem alguns esclarecimentos sobre os critérios gerais a serem utilizados para a dosimetria, especialmente sobre a forma de cálculo das frações de aumento e diminuição. A base de cálculo será o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, e não a pena mínima.

Na primeira fase, na qual fixa-se a pena-base, existem oito circunstâncias judiciais passíveis de valoração. A pena sempre partirá do mínimo previsto e, a cada circunstância judicial desfavorável ao acusado, somar-se-á à reprimenda mínima

cominada a fração de um oitavo (pois são oito circunstâncias), calculada pelo intervalo entre o máximo e o mínimo de pena previstos em lei para o crime em questão. A partir deste intervalo entre a pena máxima e a mínima encontra-se a fração respectiva de um oitavo para cada circunstância desfavorável.

Exemplificando-se, para melhor compreensão: se um crime tem pena mínima de 12 anos e máxima de 20 (como ocorre com o tipo previsto no art. 159, § 1º do Código Penal), o cálculo das frações é feito sobre o intervalo de 8 anos entre a pena mínima e máxima, e não sobre os 12 anos da pena mínima. A cada circunstância negativa considerada somar-se-á à pena mínima  $\frac{1}{8}$  sobre oito anos, o que representa um ano. Se não houver circunstância negativa, a pena-base será a mínima, de 12 anos; ao contrário, se todas forem desfavoráveis, a pena parte do máximo legal, 20 anos. Tal forma possibilita ao mesmo tempo: i) controle sobre os patamares utilizados pelo julgador, que se move em espaço conferido pelo legislador por meio de critério racional; ii) proporcionalidade, pois cada circunstância terá, em regra, peso semelhante e será calculada de acordo com os patamares mínimo e máximo da pena, abarcando de forma global a gravidade do crime; iii) fixação da pena partindo sempre do mínimo legal, com a possibilidade de se chegar ao máximo previsto, caso as oito circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis.

O critério também evita indesejáveis discrepâncias, como nos casos de crimes com pena mínima muito elevada ou diminuída. Se o cálculo partir da pena mínima, pode-se chegar a exasperações exageradas (como no caso da extorsão mediante sequestro seguida de morte, cuja pena mínima é de 24 anos) ou ínfimas (neste caso nunca se chegando perto da pena máxima cominada para o delito, como no crime de ameaça). Ademais, permite que crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta (como a lesão corporal do caput e a figura do § 9º), sejam apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei. Seria injusto que para crimes de diferente gravidade a exasperação da pena-base partisse do mesmo patamar.

Via de regra, este será o critério utilizado na primeira fase. Diante da peculiaridade de cada caso as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas, para que se possa individualizar adequadamente a pena, de forma fundamentada (como por exemplo, nos casos de várias condenações criminais ou reincidência específica). O critério explicitado servirá sempre de parâmetro, porém não impedirá seja a pena-base fixada de modo diverso (para mais ou menos) se o caso assim recomendar (valendo isto também para a segunda fase).

Na segunda fase, na qual incidem agravantes e atenuantes, a fração usada para valoração será, no mais das vezes, de um sexto ( $\frac{1}{6}$ ), calculado ou sobre o intervalo entre pena mínima e máxima, como acima, ou sobre a pena-base já fixada - o que for maior.

E utilizar-se-á o maior valor por uma razão simples: há uma hierarquia no sistema trifásico que deve ser respeitada. O sistema trifásico é escalonado, tendo cada fase maior relevância sobre a precedente. As circunstâncias do art. 59, valoradas pelo julgador, jamais podem preponderar sobre agravantes ou atenuantes, elevando a pena em patamar acima destas, que já foram estipuladas como mais graves de antemão pelo próprio legislador. A fração de  $\frac{1}{6}$  será utilizada pois é a menor prevista para as causas de diminuição e de aumento de pena e, com isso, respeita-se novamente a hierarquia do sistema trifásico.

Por fim, como não poderia deixar de ser, as causas de aumento ou de diminuição de pena incidirão sobre a reprimenda fixada provisoriamente na primeira e segunda fases, de forma sucessiva (incidindo umas sobre as outras, em cascata), segundo entendimento preponderante nos tribunais. Do contrário poderia se chegar ou a penas negativas, no caso de diversas causas de diminuição, ou na utilização de critérios distintos para causas de aumento e de diminuição, o que não é isonômico.

Friso que o critério ora explicitado vem sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (HC 498586 / SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020), verbis:

“2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte,

ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

3. As agravantes não necessariamente incidem sobre o resultado da pena-base, cujo acréscimo de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa multiplica o intervalo de pena decorrente da diferença entre a pena mínima e máxima cominadas ao tipo, para então somar à pena mínima. Portanto, as agravantes incidirão sobre a pena-base se for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haver pena concreta dosada, as agravantes serão fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, sob pena de as agravantes serem menos gravosas do que meras circunstâncias judiciais". E ainda (AgRg no REsp 1704633 / TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019): "A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base".

Dito isso, passo efetivamente a fixar a pena.

1 - Jefferson

Observo que o acusado Jefferson não ostenta antecedentes criminais, já que ambas as condenações que sofrera tiveram a prescrição da pretensão punitiva reconhecida (fls. 52/54), além de serem fatos deveras antigos e que deveriam mesmo ser descartados para tal finalidade.

Assim, estabeleço a pena-base no mínimo legal, 02 anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistentes agravantes, e a confissão não pode conduzir a pena além do mínimo (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, em razão da tentativa, diminuo a pena em metade, considerando o iter percorrido pelos agentes, que estavam na fase intermediária de execução da ação. Com isso, a pena fica em 01 ano de reclusão.

O regime inicial, tendo em vista a quantidade de pena e primariedade deve ser o aberto. Viável a substituição da pena privativa de liberdade, por reprimenda restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade a ser cumprida a critério do juízo da execução.

2 - Wesley

Antes de iniciar a dosimetria propriamente dita, observo que Wesley conta com duas condenações definitivas por roubo (fl. 70, processos da 3ª e 2ª Varas locais) e uma por furto (fl. 73) aptas a serem reconhecidas como reincidência, além de uma condenação por tráfico passível de ser considerada como antecedente criminal.

Assim, duas das condenações serão valoradas na primeira fase e duas na segunda.

Portanto, na primeira fase, deve a pena ser exasperada em 1/8, 9 meses de reclusão e 43 dias-multa, conforme critério de cálculo acima explicitado (encontro da fração a partir do intervalo entre a pena mínima e máxima do delito).

Ressalto que a pena parte do mínimo legal (2 anos) e a este patamar serão somados os montantes das frações encontradas a partir do intervalo entre a pena mínima e máxima, e não a partir da pena mínima.

NÃO SE TRATA DE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DO TERMO MÉDIO (O QUAL FARIA A PENA-BASE PARTIR DE 5 ANOS E NÃO DO MÍNIMO), TAMPOUCO DE ERRO ARITMÉTICO.

Trata-se de utilização de distinta base de cálculo para encontro das frações de mudança da pena, utilizando-se o resultado do intervalo entre a pena mínima e máxima, e não a pena mínima, critério este que considera a gravidade do crime de forma global conforme estipulada pelo legislador e mostra-se mais proporcional ao juízo prévio feito pelo parlamento sobre a natureza do crime (caso contrário, crimes com pena mínima igual e pena máxima diversas, como o estupro e o homicídio, o furto qualificado e a corrupção passiva, etc, teriam idêntico apenamento, o que não se mostra de fato adequado, pois o legislador já estabeleceu distinção prévia de gravidade, a ser observada pelo julgador; já crimes com penas mínimas muito elevadas, teriam exasperações exageradas, como a extorsão mediante sequestro com resultado morte, com pena mínima de 24 anos).

De toda forma, destaco novamente que o tópico acima ("critérios para fixação da pena") estabelece as justificativas pelas quais a individualização da pena resta melhor assegurada por esta forma de cálculo, que é diferente do padrão normalmente adotado (mais cômodo para cálculos, mas que desconsidera inúmeros fatores de

proporção e postulados a respeito da prevalência dos critérios de lei sobre critérios subjetivos), mas que é referendado por argumentos racionais e também pela jurisprudência do STJ (HC 498586/SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020 e AgRg no REsp 1704633/TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019).

Assim, a pena inicial fica em 2 anos e 9 meses de reclusão e 53 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o acusado ostenta tripla reincidência (sendo duas consideradas nesta fase), o que por questões de isonomia demandaria agravamento da pena em patamar superior a 1/6. Entretanto, confessou o crime, circunstância levada em conta para a formação da convicção sobre a condenação. Na esteira de já consolidada jurisprudência do STJ, a qual considera ser inviável a "compensação" integral no caso de múltipla reincidência (REsp 1360952/DF, 6ª Turma, Julgado em 09/12/2014 e HC 280498/SP, 5ª Turma, Julgado em 02/12/2014), apenas uma das condenações será desprezada, neutralizando-se com a confissão. Pela outra, realizo o agravamento da pena em 1/12, equivalente, pelo critério de cálculo acima explicitado (encontro da fração a partir do intervalo entre a pena mínima e máxima do delito), a 6 meses de reclusão e 39 dias-multa.

A pena então chega a 3 anos e 3 meses de reclusão e 92 dias-multa.

Por fim, diante da tentativa, diminuo tal pena pela metade e chego a uma reprimenda final de 1 ano, 7 meses e 15 dias de reclusão e 46 dias-multa.

O regime inicial, tendo em vista a gravidade em concreto do crime (furto de bem de valor não tão expressivo), quantidade de pena (abaixo de 4 anos) e reincidência, deve ser o semiaberto (súmula 269 do STJ).

Diante de tais parâmetros, inviável a substituição da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO os réus pela prática do crime de furto qualificado tentado, previsto no art. 155 § 4º, IV, do Código Penal, às seguintes penas: 1) WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA PAES: 1 ano, 7 meses e 15 dias de reclusão e 46 dias-multa, em regime inicial semiaberto, calculados os dias-multa em seu mínimo legal; 2) JEFFERSON DE OLIVEIRA PAES: 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, a qual SUBSTITUO por prestação de serviços à comunidade, a critério do juízo da execução, além de 10 dias-multa, calculados no mínimo legal.

Os réus poderão recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura a Wesley.

Condene os réus ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, com as ressalvas da gratuidade.

Com o trânsito, i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, ii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se guia de recolhimento.

Oportunamente, expeçam-se certidão de honorários aos advogados que atuaram pelo convênio.

Publique-se. Intime-se na forma legal.

Andradina, 20 de maio de 2022.

Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Juiz de Direito

(assinatura eletrônica)